

Brain & Mind

Hot Issue

치매 관련 후견인 시스템(법률적 관점에서)
김연희 / 법무법인 의성 대표변호사

치매 관련 후견인 시스템(법률적 관점에서)

시작하며

몇 년 전 진행했던 민사 사건 중, 치매 환자로서 자녀에 의해 성년후견의 개시를 구하는 심판이 청구되어 계속되는 도중에 환자가 신탁업을 하는 회사와 유언 대응 신탁계약을 체결하고 그 후 얼마 지나지 않아 한정후견 개시결정이 나게 되어, 치매 환자가 했던 신탁계약의 효력 여부에 관해 자녀들 간에 이견이 있어 결국 소송이 제기되어 다투어진 사건이 있다.

소송 절차 상 당사자는 치매 환자 본인(원고)으로 소송을 제기한 자는 후견인이고, 상대방(피고)은 신탁회사였다. 후견인은 가정법원의 허가를 얻어 신탁계약무효 확인 소송을 제기하고 신탁계약에서 불리한 내용으로 신탁재산을 배분받는 자녀들이 원고 보조참가인으로 참여하였으며, 신탁계약에서 유리한 내용으로 신탁재산을 배분받는 자녀는 피고 보조참가인으로 참여하였다. 즉, 신탁계약 무효를 주장하는 자녀는 원고측에, 유효를 주장하는 자녀는 피고측에 참가한 것이다.

1심은 신탁계약을 유효라고 보았으나 2심에서는 무효라고 판단하였고, 대법원에서 최종적으로 신탁계약이 무효라고 확정되었다. 해당 소송에서 가장 핵심적인 내용은 과연 치매 환자인 원고가 신탁계약을 체결할 당시 의사능력이 있었는지 여부였으며, 이는 결국 의학적인 판단에 기초할 수

밖에 없는 측면이 있다. 이하에서는 해당 사안의 구체적인 경과를 토대로 치매 관련 후견인 시스템을 설명하고자 한다.

성년후견과 한정후견에 관한 법률의 규정과 해당 사건의 경과

가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 한정후견인, 한정후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견 개시의 심판을 한다(민법 제93조). 해당 사안에서는 원고(서술의 편의를 위해, 이하에서는 ‘환자’라고 함.)의 자녀 A가 성년후견 개시심판 청구를 하였다가 도중에 한정후견 개시를 구하는 내용으로 변경하였다. 사무를 처리할 능력이 결여된 자에 대한 성년후견과 달리, 한정후견은 사무를 처리할 능력이 부족한 경우에 이루어진다. 환자는 당시 경도 인지장애 진단을 받은 상황이었다.

가정법원의 성년후견 개시심판이 있는 경우에는 그 심판을 받은 사람의 성년후견인을 두어야 한다(민법 제929조). 한정후견 개시의 심판이 있는 경우에도 한정후견인을 두어야 한다(민법 제959조의2).*

성년후견인은 피성년후견인의 신상과 재

산에 관한 모든 사정을 고려하여 여러 명을 둘 수 있고, 법원도 성년후견인이 될 수 있다(민법 제930조). 성년후견인은 가정법원이 직권으로 선임하는데, 이때 피성년후견인의 의사를 존중하여야 하며, 그 밖에 피성년후견인의 건강, 생활 관계, 재산 상황, 성년후견인이 될 사람의 직업과 경험, 피성년후견인과의 이해관계의 유무(법원이 성년후견인이 될 때에는 사업의 종류와 내용, 법인이거나 그 대표자와 피성년후견인 사이의 이해관계의 유무를 말한다) 등의 사정도 고려하여야 한다(민법 제936조). 피후견인을 상대로 소송을 하였거나 하고 있는 사람 그리고 그의 배우자와 직계혈족(다만, 피후견인의 직계비속은 제외)은 후견인이 될 수 없다(민법 제937조). 이 사건은 비록 소송은 나중에 이루어졌지만, 후견 개시 심판청구를 할 무렵에 이미 자녀들 간 재산에 관한 다툼이 있어, 가정법원은 한정후견 개시 결정 전에 직권으로 환자에 대해 임시후견인(사회복지법인)을 선임하였다가 한정후견 개시 결정이 확정되면서 변호사 000를 한정후견인으로 선임하였다.

후견인은 피후견인의 법정대리인이 되며, 가정법원은 성년후견인의 법정대리권의 범위를 정할 수 있고, 성년후견인이 피성년후견인의 신상에 관하여 결정할 수 있는 권한의 범위를 정할 수도 있다(민법 제938조). 후견인은 피후견인의 재산을 조사

*성년후견과 한정후견제도는 절차상으로는 대동소이하고 실질적인 내용에서 차이가 있으므로, 이하에서는 성년후견에 관한 조문과 그 내용을 위주로 기재한다.

하여 목록을 작성하여야 하고(민법 제941조), 피성년후견인의 복리와 의사를 존중하여야 한다(민법 제947조). 피성년후견인은 자신의 신상에 관하여 그의 상태가 허락하는 범위에서 단독으로 결정할 수 있다. 성년후견인이 피성년후견인을 치료 등의 목적으로 정신병원이나 그 밖의 다른 장소에 격리하려는 경우에는 가정법원의 허가를 받아야 하고, 피성년후견인의 신체를 침해하는 의료행위에 대하여 피성년후견인이 동의할 수 없는 경우에는 성년후견인이 그를 대신하여 동의할 수 있으나, 피성년후견인이 의료행위의 직접적인 결과로 사망하거나 상당한 장애를 입을 위험이 있을 때에는 가정법원의 허가를 받아야 한다. 성년후견인이 피성년후견인을 대리하여 피성년후견인이 거주하고 있는 건물 또는 그 대지에 대하여 매도, 임대, 전세권 설정, 저당권 설정, 임대차의 해지, 전세권의 소멸, 그 밖에 이에 준하는 행위를 하는 경우에는 가정법원의 허가를 받아야 한다(민법 제947조의2). 후견인은 피후견인의 재산을 관리하고 그 재산에 관한 법률행위에 대하여 피후견인을 대리한다(민법 제949조).

후견이 개시되면 이러한 후견에 관한 사항을 후견등기에 기록하여 공시한다(가사소송법 제9조). 등기사항은, 후견의 종류, 피후견인 당사자, 후견 개시 및 종료에 관한 사항, 후견인에 관한 사항, 대리권등 목록(피후견인이 후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위, 후견인이 동의를 함에 있어 사전에 법원의 허가를 받아야 하는 행위의 범위 등, 후견인의 대리권의 범위, 후견인이 피후견인의 신상에 관하여 결정할 수 있는 권한의 범위 등)이다(후견등기

에 관한 법률 제25조 제1항). 후견 관련 사항의 증명이 필요한 사람은 전국 가정법원 또는 가정법원 지원(가정법원 및 가정법원 지원이 설치되어 있지 않은 지역은 지방법원 및 지방법원 지원)의 가족관계등록과 또는 종합민원실에서 등기사항증명서 또는 등기사항부존재증명서를 발급받을 수 있다. 등기사항증명서는 후견인 등이 피후견인을 대리하여 재산의 매매계약이나 간호서비스 제공계약을 체결할 경우 거래의 상대방에게 이를 제시하여 자신의 대리권을 증명하기 위해 발급받을 수 있고, 등기사항부존재증명서는 거래 시점 현재 효력이 있는 성년후견, 한정후견, 특정후견, 임의후견 등의 후견등기사항이 존재하지 않음을 나타내는 증명서이다. 후견등기에 관한 정보는 사람의 판단 능력에 대한 법원의 판단을 내용으로 하는 고도의 프라이버시에 관한 사항이므로, 등기사항증명서 또는 등기사항부존재증명서는 피후견인, 배우자, 4촌 이내의 친족과 후견인, 후견감독인 및 각 직에서 퇴임한 자 그 밖에 법령상 규정된 사람만이 발급받을 수 있으며 거래 상대방이라는 사유만으로는 발급받을 수 없다.

이 사건에서 한정후견인이 결정할 수 있는 권한의 범위는 [의료행위의 동의, 거주·이전에 관한 결정, 면접·교섭에 관한 결정, 우편·통신에 관한 결정, 사회복지서비스 선택 또는 결정]이었고, 한정후견인의 대리권의 범위는 [재산관리에 관한 사항(부동산의 관리·보존·처분, 예금 등의 관리, 보험에 관한 사항, 정기적 수입 및 지출에 관한 관리, 상속의 승인, 한정승인 또는 포기 및 상속재산의 분할에 관한 협의, 물품의 구입·판매, 서비스 이용

계약의 체결·변경·종료, 유채동산, 증서 및 중요문서 등의 보관 및 관리, 세무신고 등 공법상의 권리, 상속인 금융거래 조회 서비스를 통한 금융거래 등 정보 확인)과 신상보호에 관한 사항(개호 및 복지서비스의 이용, 의료계약의 체결·변경·종료 및 비용의 지급, 주민등록이나 공적의료보험 및 국민기초생활수급의 신청 및 갱신 등 공법상의 행위), 소송행위, 취소권 행사 후 원상회복과 관련한 사항]이었으며 그 중 금전을 빌리는 행위, 의무만을 부담하는 행위, 부동산 및 주식의 처분 또는 담보제공 행위, 상속의 포기 또는 상속재산의 분할에 관한 협의, 소송행위 및 이를 위한 변호사 선임행위, 주주권 행사와 관련한 사항은 법원의 허가를 받도록 정하였다. 따라서 이후 이루어진 소송제기(환자가 신탁회사를 상대로 신탁계약무효확인 소송을 제기)는 환자의 한정후견인이 가정법원의 허가를 받아 행해진 것이다.

가정법원은 필요하다고 인정하면 직권으로 또는 피성년후견인, 친족, 성년후견인, 검사, 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견감독인을 선임할 수 있다(민법 제940조의4). 후견감독인은 후견인의 사무를 감독하며, 피후견인의 신상이나 재산에 대하여 급박한 사정이 있는 경우 그의 보호를 위하여 필요한 행위 또는 처분을 할 수 있고, 후견인과 피후견인 사이에 이해가 상반되는 행위에 관하여는 후견감독인이 피후견인을 대리한다(민법 제940조의6). 후견감독인은 언제든지 후견인에게 그의 임무 수행에 관한 보고와 재산목록의 제출을 요구할 수 있고 피후견인의 재산상황을 조사할 수 있다(민법 제953조). 해당 사건은 가족이 아닌 제3자인 변

호사가 한정후견인으로 선임되었으므로 후견감독인이 별도로 선임되지는 않았다.

후견 개시 이후에 행한 피후견인이 법률 행위에 대해서는 당연히 후견인이 개입할 수 있고, 해당 사건에서 알 수 있듯이, 피후견인이 후견 개시 이전에 했던 법률행위에 대해서도 피후견인의 이익에 반하거나 행위의 의미를 모르고 한 행위에 대해서는 후견 개시된 이후에 취소나 무효로 돌릴 수 있다.

그 외 특정후견과 후견계약

우리 민법상, 위에서 언급한 성년후견과 한정후견 이외에도 특정후견과 후견계약 제도가 있다. 치매 환자의 경우에는 특정후견이나 후견계약보다는 성년후견이나 한정후견이 적합할 수 있지만, 치매의 정도가 경미하여 정신적 제약 여부가 불확실한 경우도 있기에 특정후견이나 후견계약이 이루어지다가 치매가 진행되면서 성년후견 또는 한정후견이 개시될 수도 있다.

특정후견은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 '일시적 후원' 또는 '특정한 사무에 관한 후원'이 필요한 사람에 대하여 이루어지고, 본인의 의사에 반하여 할 수 없으며, 특정후견의 기간 또는 사무의 범위를 정하여야 한다(민법 제14조의2). 따라서 본인의 행위능력이 제한되지 않는다.

후견계약은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 '사무를 처리할 능력이 부족한 상황에 있거나 부족하게 될 상황'에 대비하여 자신의 재산관리 및 신상보호에 관한 사무의 전부 또는 일부를 다른 자에게 위탁하고 그 위탁사무에 관하여 대리권을 수여하는 것을 내용으로 한다(민법 제959조의14 제1항). 후견계약은 공정증서로 체결하여야 하며(민법 제959조의14 제2항), 가정법원이 임의후견감독인을 선임한 때부터 효력이 발생한다(민법 제959조의14 제3항). 성년후견과 한정후견 및 특정후견이 법정후견인 것과 달리 후견계약은 당사자가 정할 수 있는 임의후견이다. 그러나 당사자가 그 내용과 범위를 계약에 의해 정할 수 있다고 하더라도, 법원의 개입을 최소화한 후견제도일뿐 모든 내용을 아무런 제한 없이 정할 수 있다는 의미는 아니다. 여전히 법원의 감독을 받게 된다. 가정법원은 본인의 이익을 위하여 특별히 필요할 때에만 임의후견인 또는 임의후견감독인의 청구에 의하여 성년후견, 한정후견 또는 특정후견의 심판을 할 수 있다. 이 경우 후견계약은 본인이 성년후견 또는 한정후견 개시의 심판을 받은 때 종료된다(민법 제959조의20).

마치며

성년후견제도 시행 이전 민법상 금지산자·한정치산자 제도가 있었는데, 말 그대로 재산을 관리하고 처분하는 능력과 관련하여 가정법원이 행위 능력을 제한하는 선고를 하는 것에 중점을 두는 것으로, 이는 본인의 복리에는 적합하지 않은 제도였다. 법정 순위에 따라 후견인이 자동으로 지정되고 법원의 감독도 받지 않아 후견인이 본인의 이익과 상반되는 행위가 이루어지는 경우도 많았고, 의료행위를 제공받는 것과 관련해서도 뚜렷한 기준이 없어 혼선이 있었다. 현재 시행되고 있는 성년후견 제도는 본인에게 잔존하는 의사결정능력을 최대한 존중하고 이익에 부합하면서도, 가족이나 거래 상대방의 불측의 손해를 막기 위해 고안된 제도이다. 고령화 사회에 접어들면서 치매 환자가 증가할 수밖에 없는 현 상황에서 그래도 지난 10여 년간 제도가 시행되면서 어느 정도 정착 단계를 거쳤고 제도 개선에 대한 다양한 의견들도 제안되고 있어, 향후 더욱 발전된, 그리고 우리나라 상황에 적합한 제도로 운영되기를 기대해 본다.